

1011342-36.2017.8.26.0053

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Suspensão da Exigibilidade

Magistrado: Celina Kiyomi Toyoshima

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 4ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... (não é imposto sobre contratos ou sobre o tráfico jurídico), mas grava as operações de circulação de mercadorias, no caso a circulação da energia, sendo que se encontra na legislação federal, como exaustivamente comprovado, a eleição do momento de ocorrência do fato gerador saída da energia elétrica das linhas de transmissão da concessionária e entrada no estabelecimento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

4ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1011342-36.2017.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1011342-36.2017.8.26.0053 - Mandado de Segurança Cível

Impetrante:

TNT Mercurio Cargas e Encomendas Express Ltda e outros

Impetrado:

Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Celina Kiyomi Toyoshima

Vistos.

TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS LTDA impetrou o MANDADO DE SEGURANÇA contra ato do SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO alegando, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado atuante no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos e não perigosos, bem como os serviços de entrega rápida e de malote não realizados pelo Correio Nacional, além da atividade de despachantes aduaneiros e de agenciamento marítimo e, no desempenho de suas atividades, consome energia elétrica. Aduz que para garantir o fluxo de energia necessário celebrou "Contrato por Demanda", tipo de contrato que garante ao consumidor o contínuo fornecimento de energia e potência previamente estabelecidos. Contudo, se a energia consumida for menor que a contratada, o valor a ser pago não sofre redução, arcando, assim, também com o pagamento do ICMS sobre a energia não utilizada. Requer, assim, seja declarado seu direito ao recolhimento do ICMS apenas sobre a energia efetivamente consumida, bem como a compensação dos valores recolhidos a maior nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Vieram as informações.

O Ministério Público não quis opinar.

É o relatório.
Decido.

O caso é de concessão da segurança.

A aquisição de energia elétrica para reserva, formalizada por contrato, não induz a transferência do bem adquirido, porque não se dá a tradição. Somente com a saída do bem adquirido do estabelecimento produtor e o ingresso no estabelecimento adquirente é que ocorre o fato gerador do ICMS.

Isso exclui do cálculo do ICMS o valor da demanda reservada de potência quando não houver o respectivo fornecimento.

Vale trazer a contexto o voto vencedor exarado pelo Min. José Delgado, do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 222810/MG:

"O ICMS incide sobre o valor da energia elétrica que tenha sido concretamente consumida pela empresa, em virtude de que somente essa quantidade é que deve ser considerada como utilizada... Assim, como são nítidas in casu dois valores correspondentes a duas situações fáticas distintas (numa, fornecimento de energia, noutra, garantia de potência), e uma destas situações não chega a configurar o fato gerador do ICMS, somente caberá falar da incidência do imposto sobre o valor da operação de que resultou a entrega de energia e não daquela que resultou mera garantia de potência.... Ora, o ICMS não grava o negócio jurídico da compra e venda (não é imposto sobre contratos ou sobre o tráfico jurídico), mas grava as operações de circulação de mercadorias, no caso a circulação da energia, sendo que se encontra na legislação federal, como exaustivamente comprovado, a eleição do momento de ocorrência do fato gerador saída da energia elétrica das linhas de transmissão da concessionária e entrada no estabelecimento do consumidor. "

Destarte, como já dito, não incide o ICMS sobre energia elétrica posta à disposição de consumidor, mas não consumida efetivamente.

Nesse sentido também é o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação Cível - Tributário - ICMS - Incidência do ICMS sobre demanda contratada e não sobre a efetivamente consumida - Magistrado que julga extinta a ação em relação à requerida Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (art. 269, III, do CPC) e julga procedentes os pedidos deduzidos na inicial em relação à Fazenda do estado de São Paulo - Recurso da Fazenda Estadual - Provimento parcial de rigor.

1. Dou por interposto o reexame necessário, nos termos do artigo 475 do Código de Processo Civil.

2. Agravo Retido - Arbitramento dos honorários periciais em valor razoável pelo Magistrado de primeiro grau - Agravo retido conhecido, pois reiterado em razões recursais e, no mérito, improvido.

2. Ilegitimidade ativa "ad causam" não configurada - Autora que suportou diretamente o encargo tributário, sendo consumidora final de energia elétrica - Conclusão pericial não é desprovida de fundamento e as críticas contra ela assacadas não prosperam porquanto, especificamente, nada se demonstrou ou indicou a desamparar as informações coletadas - Preliminares rejeitadas.

3. No Mérito, inadmissível a incidência do ICMS sobre energia elétrica disponibilizada porém não efetivamente consumida - Não ocorrência de fato gerador do imposto (circulação de mercadoria) - Pretensão de exação descabida - Precedentes da Câmara, Recurso Especial repetitivo nº 960476 / SC e Súmula nº 391 do STJ - Restituição dos valores cobrados - correção monetária desde o indevido desconto, com base na Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, a partir

do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN - Observada a prescrição quinquenal.

4. Honorários advocatícios fixados em valor excessivo - Redução para 5% do valor da condenação - Critério equitativo - Artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil. R. Sentença parcialmente reformada - Preliminares rejeitadas - Agravo retido desprovido - Reexame Necessário e Recurso da Fazenda do Estado parcialmente providos apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau." (Relator(a): Sidney Romano dos Reis; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 31/08/2015; Data de registro: 02/09/2015)

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - DEMANDA CONTRATADA - CONTRIBUINTE DE FATO - LEGITIMIDADE ATIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER - LEGITIMIDADE PASSIVA - INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

1. O Colendo STJ pacificou o entendimento de que o contribuinte de fato tem legitimidade ativa ad causam para questionar a incidência de ICMS sobre a demanda de energia elétrica contratada e não utilizada. Adequação do julgado. Necessidade. Causa extintiva da ação afastada.

2. Concessionária de energia elétrica. Legitimidade passiva ad causam para responder a pedido de condenação em obrigação de não-fazer consistente na abstenção de cobrança do imposto nas contas de consumo de energia elétrica. Extinção do processo afastada.

3. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Súmula 391 do STJ. Sentença reformada. Pedido procedente. Recurso provido." (Relator(a): Décio Notarange; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 27/05/2015; Data de registro: 28/05/2015; Outros números: 7150545200)

"AÇÃO ORDINÁRIA - ICMS Energia Elétrica Contrato de demanda reservada de potência - Legitimidade "ad causam" da consumidora final reconhecida, conforme REsp nº

1.299.303/SC Fato Gerador - Base de cálculo do tributo estadual que também inclui a parcela relativa à demanda reservada ou contratada - Inadmissibilidade - Fato gerador do ICMS que somente ocorre no momento em que o produto é entregue ao consumidor - A hipótese de incidência tributária é a circulação da mercadoria, no caso, sua utilização efetiva pelo consumidor Juros moratórios que correrão a partir do trânsito em julgado da ação, nos termos do art. 167, par. único, do CTN Correção monetária a contar a partir de cada recolhimento indevido (Súmula 162, STJ) - Recurso voluntário da ré não provido e acolhido em parte o reexame necessário tão somente para fixar o termo inicial dos juros moratórios e a correção monetária a contar a partir de cada recolhimento indevido (Súmula 162, STJ) - Precedentes desta E. Corte." (Relator(a): Rebouças de Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 11/03/2015; Data de registro: 12/03/2015)

Ademais, impende salientar que, neste particular, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 391 no seguinte teor: "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada".

Destarte, de rigor a procedência da ação, com a compensação das cobranças reconhecidas como indevidas.

Nesse sentido, é também o entendimento do E. STJ:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS E DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR DE FATO (CONTRIBUINTE FINAL) PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO, A FIM DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.299.303/SC, REL. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, DJE

14.8.2012, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO VISANDO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM QUALQUER EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO FISCO COMPETENTE. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS 1.715.294/SP E 1.365.095/SP, SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTE DO CÓDIGO FUX. INAPLICABILIDADE DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 69 E 271 DO STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.299.303/SC, representativo de controvérsia, realizado em 8.8.2012, da relatoria do ilustre Ministro CESAR ASFOR ROCHA, firmou entendimento de que o consumidor final tem legitimidade para o ajuizamento de ação, a fim de afastar a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada no tocante ao fornecimento de energia elétrica. 2. Também se encontra consolidada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.715.256/ SP e 1.365.095/SP, julgados sob o regime de recursos repetitivos, a orientação de que, na hipótese de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco. 3. Sendo assim, declara-se o direito de compensabilidade dos valores recolhidos de forma indevida, ressaltando que os critérios a serem utilizados na futura compensação deverão ser analisados, oportunamente, na esfera administrativa, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e controle do procedimento compensatório. Logo, inaplicável, na hipótese, das Súmulas 269 e 271 do STF. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento". (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 434.106/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020).

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e declaro EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para declarar a abstenção da ré em exigir o pagamento do ICMS sobre a energia elétrica reservada, devendo incidir tão somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida, bem como o dever de compensar os valores indevidamente recolhidos a maior.

Custas, na forma da lei. Sem honorários advocatícios. Oportunamente, subam para o reexame necessário.

A presente sentença servirá como ofício (vide art. 13 da lei nº 12.016/2009), intimando-se os impetrados do inteiro teor desta.

P.R.I.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.